

1501908-35.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/04/2022

... condição de dependente químico não elide a prática do delito de tráfico de drogas." (TJAC - Processo: EI 10414920108010001 AC 0001041-49.2010.8.01.0001 -

Relator(a): Pedro Ranzi - Julgamento: 27/04/2011 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno - Publicação: 30/04/2011).

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA. SUFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Sala 7, Alemães - CEP 13417-100, Fone: (19)3372-3084, Piracicaba-SP - E-mail: piracicaba2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1501908-35.2021.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2339016/2021 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 21929433 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO,

3574/21/922 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2339016 - 02º D.P. PIRACICABA,

3574/21/922 - 02º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS MARCEL PEREIRA CARDOSO

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

*

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 05 dias do mês de abril de 2022, à hora designada, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, apresentaram-se a Exma. Sra. Dra. FLAVIA DE CASSIA GONZALES DE OLIVEIRA, MMª Juíza de Direito, o representante do Ministério Público, Dr. Denis Peixoto Parron e o(a) Defensor(a) Público(a), Dr(a).Flavia Stringari Machado. Apresentados o(a)(s) acusado(a)(s) DOUGLAS MARCEL PEREIRA CARDOSO, e as testemunhas arroladas em comum pelas partes Douglas Walter Radeschi de Toledo e Edivaldo da Silva Santos.

Fica consignado que foi assegurado o direito de entrevista do(a)(s) acusado(a)(s) com seu(sua)(s) defensor(a)(es), em reunião virtual apartada, no estrito

cumprimento do artigo 185, § 5º, do C.P.P., tendo a MM Juíza feito ao(a)(s) acusado(a)(s) a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal. INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foi(ram) colhido(s) o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) (Douglas e Edivaldo) pelo sistema virtual e, em seguida, interrogado(a)(s) o(a)(s) réu(ré)(s).

Em seguida, pela MM Juíza foi deliberado:

"Não havendo mais provas a serem produzidas, encerro a instrução, determinando às partes que passem aos debates orais:

Dada a palavra ao(à) ilustre representante do Ministério Público, manifestou-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juíza, DOUGLAS MARCEL PEREIRA CARDOSO está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Feito regularmente processado.

Procede a ação penal.

DOS FATOS, com indicação de provas da materialidade e autoria delitivas Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 13 de dezembro de 2021, por volta de 16h40min, na Rua João Candido Rosa, n.º 98, Novo Horizonte, nesta cidade e Comarca de Piracicaba/SP, DOUGLAS MARCEL PEREIRA CARDOSO, qualificado e indiciado às fls. 04/05 e 24/28, trazia consigo, para entregar ou fornecer ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 07 (sete) eppendorfs contendo cocaína, com peso líquido de 1,2g (um grama e dois decigramas) (item 3) e 10 (dez) porções de crack, substância derivada da cocaína, com peso líquido de 1,1g (um grama e um decigrama) (item 04), e guardava, para entregar ou fornecer ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 42 (quarenta e duas) porções de crack, substância derivada da cocaína, com peso líquido de 5g (cinco gramas) (item 01) e 51 (cinquenta e um) eppendorfs contendo cocaína, com peso líquido de 12,7g (doze gramas e sete decigramas) (item 2), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, o denunciado estava comercializando porções de cocaína e crack no endereço acima descrito. Estratégia comum na traficância, trazia poucas porções consigo e escondia maiores quantidades em local próximo a seu "ponto de venda".

Ocorre que, ao sair de um terreno baldio, DOUGLAS se deparou com policiais militares e - em comportamento notadamente furtivo - adentrou numa padaria. Abordado e revistado, foi localizada em sua posse uma pochete contendo 07 (sete) eppendorfs de cocaína, 10 (dez) porções de crack e R\$30,00 (trinta reais) em espécie. Informalmente, o denunciado confirmou a prática delitiva e indicou o local, no interior do terreno baldio, onde escondia outras 51 (cinquenta e um) eppendorfs de cocaína e 42 (quarenta e duas) porções de crack.

Na delegacia, DOUGLAS afirmou que escondia apenas 10 (dez) porções de cocaína no terreno, as quais seriam comercializadas. Negou a propriedade das demais drogas (fls. 04/05).

Em exame pericial, foi constatada a presença de Cocaína nas substâncias apreendidas (auto de exibição fls. 10/11, foto fls. 12 e laudos periciais fls. 15/18 e 74/75).

DA PROVA ORAL NA FASE JUDICIAL

Edivaldo da Silva Santos - Policial Militar - narrou que estava em patrulhamento e em local conhecimento com ponto de venda de drogas, onde tem um terreno baldio no qual traficantes escondem drogas. Viu quando o réu saiu do terreno, atravessou a rua e entrou em uma padaria. Abordou-o. ele tinha uma bolsa a tiracolo, na qual tinham sete porções de cocaína, dez de crack e dinheiro. Ele confirmou que estava vendendo porque precisava de dinheiro. E ele disse que embaixo de uma porta quebrada no terreno tinham mais drogas. Foi até lá e encontrou cinquenta e uma porções de cocaína e quarenta e duas porções de crack. O terreno tem vários entulhos e foi o réu quem informou onde estavam escondidas as porções, embaixo da porta. Levou o réu ao plantão policial. Acredita que já abordou o réu, mas não tem certeza.

No mesmo sentido, o PM Douglas Walter Radeschi de Toledo.

Interrogado, o réu negou os fatos. Disse que tinha apenas dois pinos de maconha e dinheiro em seu poder. Que indicou aos policiais onde estavam dez pinos de cocaína no terreno. Mas era pra seu consumo pessoal. Não tem responsabilidade sobre as

demais porções.

Não há dúvidas sobre os fatos.

Diante das circunstâncias, notadamente a visualização de movimentação típica de mercancia ilícita, a condição pessoal do agente, a apreensão de porções de crack e cocaína em quantidade e forma incompatíveis com a mera destinação pessoal, acompanhadas de dinheiro em espécie, é certo que o denunciado trazia consigo e guardava os entorpecentes com a finalidade de comércio ilícito.

As palavras dos agentes policiais merecem credibilidade e possuem força probatória suficiente para a prolação da sentença condenatória, mormente porque não conheciam o réu e não tinham motivo algum para incriminá-lo gratuitamente (Apelação Criminal nº 990.08.153847-4, 8ª Câmara Criminal, rel. Des. André de Oliveira, julgada em 13/03/2009).

Os policiais apenas encontraram as porções porque o réu indicou o lugar onde estavam: embaixo de uma porta velha. Mas o réu disse que eram apenas dez porções de cocaína. Porém, essas dez porções estavam em poder do réu e, sob a porta, os policiais encontraram quase uma centena de porções de crack e cocaína. É certo que pertenciam ao réu. Embaladas da mesma forma (fls. 12) e apenas encontradas porque o réu apontou o local onde estavam.

Com relação ao argumento do réu de que não chegou a nada comercializar, nem se alegue que tal seria necessário, pois não é necessária a prática de ato de comércio, ainda mais quando não há dúvida de que o entorpecente seria destinado à venda. No ponto: "A prova mostra, ainda, que a droga era destinada ao comércio, mormente pela expressiva quantidade, pela forma de acondicionamento e pela postura do acusado, que inclusive admitiu o comércio espúrio. De mais a mais, nunca é demais lembrar que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou guarde a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado.

Dentro dessas premissas, não se tem dúvida de que o entorpecente apreendido seria destinado à venda, de sorte que o delito está bem caracterizado. A condenação do recorrente pelo tráfico, portanto, foi bem decretada." TJ/SP, 0005411-

25.2010.8.26.0050 Apelação, Relator(a): Pinheiro Franco, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 10/11/2011, Data de registro: 11/11/2011).

Saliento que o fato de se declarar usuário de drogas, não afasta a possibilidade de que o mesmo exerça a traficância ilícita de entorpecentes, até porque muitos dependentes de tóxicos utilizam desse expediente para financiar o próprio vício. Nesse sentido: "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP - HC 42.229- 3 - Rel. Onei Raphael - RJTJSP 10/498).

E não há se falar em absolvição fundada em suposta dificuldade financeira, uma vez que esta situação não caracteriza estado de necessidade, nem se amolda a qualquer excludente de culpabilidade. Além disso, não poderia o agente criminoso valer-se de meio ilícito para obter seu sustento. "Crime de tráfico - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito - Transporte interestadual - Confissão da ré que se ajusta a esse quadro - Estado de necessidade afastado - Justificativa de dificuldades financeiras que não afasta a punibilidade - Pena base fixada no mínimo legal previsto, compensada a causa de aumento com a causa de redução por frações iguais - Pena adequada - Recurso não provido." (Apelação 990080746367, 16ª Câmara de Direito Criminal TJ/SP, relator Newton Neves, julgado em 23.03.10)

DA PENA

Folha de antecedentes e certidões já providenciadas (fls. 41/49): DOUGLAS MARCEL PEREIRA CARDOSO ostenta maus antecedentes -condenado por tráfico de drogas nos autos 3011627-04.2013.8.26.0451 (fls. 41: pena extinta, pelo cumprimento, em 10.05.2016).

Pena acima do mínimo legal e regime fechado inicial.

Por óbvio, não é possível o Acordo de Não Persecução Penal (CPP, art. 28-A).

Não é possível a diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06:

réu com maus antecedentes, o que demonstra, ainda, envolvimento e dedicação ao tráfico de drogas desde longa data.

Também não se mostra cabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Há de se considerar a considerável quantidade de entorpecentes apreendidos.

Ora, as circunstâncias especiais do fato, a quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas, mais nocivas à saúde e com maior potencial de levar o usuário à dependência devem ser levadas em consideração na dosimetria da pena, servindo-se para afastar o benefício legal acima mencionado. (RT 775/559).

É o que permite o artigo 42 da Lei 11.343/06.

Vale reforçar que, em que pese o Colendo Supremo Tribunal Federal ter reconhecido a inconstitucionalidade do art. 44 da Lei nº 11.343/06 por ocasião do julgamento do HC nº 97.256/RS, e a resolução do Senado Federal suspendendo a execução de parte do dispositivo legal, a vedação de se aplicar penas restritivas ao crime de tráfico continua sendo possível quando as circunstâncias do art. 44, III, do Código Penal indicarem não ser recomendável a substituição, como ocorre no caso em apreço. E, definitivamente, não se demonstra razoável conceder tamanho beneplácito aos que praticam tão grave crime.

Ao contrário, estes merecem severa reprimenda, pois se trata de crime em que a base da sociedade é atingida, distorcendo regras e valores dos jovens, de forma a aumentar a já tão elevada criminalidade. O traficante age sem qualquer escrúpulo, com exclusiva intenção de lucro, não se importando em destruir diversos lares e famílias quando leva ou mantém no vício um de seus integrantes.

O legislador, ao equiparar o crime de tráfico ilícito de entorpecentes aos crimes hediondos, em norma constitucional (art. 5º, XLIII, da CF), deixou claro seu intuito em dar tratamento rigoroso aos que praticam este crime, determinando, ainda, que o regime inicial de cumprimento de pena será, obrigatoriamente, o fechado (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90).

O E. Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, embora sem impedimento legal, é incompatível com a condenação por crime hediondo, mesmo que equiparado, em razão da periculosidade social presumida, que incompatibiliza o autor do crime com atividades comunitárias ou assistenciais na medida em que o coloca em contato direto com grupo social passível de seu assédio. Ademais, em face do contexto em que o crime foi praticado, que exterioriza a personalidade do agente e seu desprezo pela vida em sociedade, eis que o envolvimento com o tráfico fomenta a multiplicação de outros crimes, não se mostra suficiente a referida benesse. Isso porque, com base no art. 44, III, do CP, tem-se que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos somente se mostra adequada quando suficiente ao atendimento das finalidades retributiva, preventiva e reprovadora da conduta, o que não se mostra no presente caso (TJ/SP, Apelação 0006123-68.2013.8.26.0451, Comarca de Piracicaba, 13ª Câmara de Direito Criminal, v.u., Des. Rel. Augusto de Siqueira, j. em 08 de maio de 2014, publicada no dia 27 de maio de 2014).

Deve ser decretado o perdimento do dinheiro apreendido em poder do réu, com base no art. 63, Lei n. 11.343/06.

DO PEDIDO FINAL

Pela procedência da ação nos termos da inicial.

Dada a palavra ao(à) nobre defensor(a) do(a)(s) acusado(a)(s), manifestando-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juiza, Douglas Marcel Pereira Cardoso foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Segundo a denúncia (fls. 86-88), no dia 13 de dezembro de 2021, por volta de 16h40min, na rua João Candido Rosa, n.º 98, Novo Horizonte, nesta cidade e comarca de Piracicaba/SP, Douglas trazia consigo, para entregar ou fornecer ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 7 (sete) eppendorfs contendo cocaína, com peso líquido de 1,2g (um grama e dois decigramas) (item 3) e 10 (dez) porções de crack, substância derivada da cocaína, com peso líquido de 1,1g (um grama e um decigrama)

(item 4), e guardava, para entregar ou fornecer ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 42 (quarenta e duas) porções de crack, substância derivada da cocaína, com peso líquido de 5g (cinco gramas) (item 1) e 51 (cinquenta e um) eppendorfs contendo cocaína, com peso líquido de 12,7g (doze gramas e sete decigramas) (item 2), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ainda de acordo com a inicial, o réu estava comercializando porções de cocaína e crack no endereço acima descrito. Estratégia comum na traficância, trazia poucas porções consigo e escondia maiores quantidades em local próximo a seu "ponto de venda". Ocorre que, ao sair de um terreno baldio, Douglas se deparou com policiais militares e - em comportamento notadamente furtivo - adentrou numa padaria.

Abordado e revistado, foi localizada em sua posse uma pochete contendo 7 (sete) eppendorfs de cocaína, 10 (dez) porções de crack e R\$30,00 (trinta reais) em espécie. Informalmente, o réu confirmou a prática delitiva e indicou o local, no interior do terreno baldio, onde escondia outras 51 (cinquenta e um) eppendorfs de cocaína e 42 (quarenta e duas) porções de crack. Na delegacia, Douglas afirmou que escondia apenas 10 (dez) porções de cocaína no terreno, as quais seriam comercializadas. Negou a propriedade das demais drogas (fls. 4/5).

Interrogado em solo policial, o réu "limitou-se a falar que acabara de esconder dez porções de cocaína num terreno baldio quando foi surpreendido pela polícia militar. Venderia as porções para ganhar dinheiro. Não disse de onde vieram as substâncias e negou que a totalidade da droga lhe pertencia" (fls. 4/5). Em Juízo, negou a prática do crime de comércio espúrio de substâncias, disse que havia escondido 10 pinos de cocaína no terreno, mas que as drogas se destinavam ao seu consumo pessoal.

Douglas Walter Radeschi de Toledo, policial militar, contou que: "estava em patrulhamento ostensivo de rotina pelo bairro Novo Horizonte. Em determinado momento, passou por um local já conhecido como ponto de venda de drogas, sendo que há um terreno baldio onde é costume se esconder entorpecentes pelos traficantes. No momento em que passava pelo local, uma pessoa saiu do terreno baldio em comento e, ao avistar a viatura, adentrou numa padaria localizada do outro lado da via, sendo abordado para averiguação. Na posse desse indivíduo havia uma pochete, dentro da qual foram localizadas sete porções de cocaína, dez porções de crack e o valor de trinta reais. De maneira informal, o indiciado confessou que estava na prática do tráfico de drogas e que havia mais substâncias escondidas no terreno acima mencionado, as quais estariam embaixo de uma porta quebrada. Seu parceiro de farda se dirigiu ao local e encontrou mais cinquenta e uma porções de cocaína e quarenta e duas porções de crack. Disse que foi o Acusado quem indicou o local onde a droga - que foi encontrada no terreno - estava" (fls. 2).

No mesmo sentido a versão apresentada pelo policial militar Edivaldo da Silva Santos (fls. 3).

Às fls. 41-42, juntada certidão de objeto e pé que indica os maus antecedentes do requerido (autos n.º 3011627-04.2013.8.26.0451 - tráfico de drogas - pena cumprida ou julgada extinta em 10/5/2016).

- DA DESCLASSIFICAÇÃO: INCIDÊNCIA DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS

Ante a prova colhida, impõe-se reconhecer que os elementos de prova produzidos em juízo não são suficientes para a constatação do delito de tráfico de drogas, mas, sim, para a configuração do uso de entorpecentes (LD, art. 28), uma vez que não demonstrado, de maneira inequívoca, o intuito de comercialização da droga e a quantidade de entorpecente apreendida na posse do réu é compatível com o uso de drogas.

Nessa linha de raciocínio, em recente decisão, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos Autos da Revisão Criminal n. 0025831-60.2017.8.26.0000, valendo-se de pesquisas científicas efetuadas para diferenciar o traficante do usuário, rescindiu condenação proferida pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas, entendendo que os fatos estariam melhor enquadrados no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Nas palavras da Eminente Relatora, "No tocante à quantidade, creio ser importante verificar pesquisas científicas sobre o tema e o 'Estudo Técnico para

Sistematização de dados sobre informações do requisito objetivo da lei 11.343/2006', de autoria de Maria Tereza Uille Gomes, de 2014, disponível em www.politicassobredrogas.pr.gov.br, traz valiosas informações de pesquisas científicas realizadas no Brasil. Vejamos: 'Estudo realizado através de pacientes da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, constatou que os pacientes viciados em cocaína utilizavam diariamente esta espécie de droga, na forma de sal, em variação de 1 a 10 (um a dez) gramas/dia, com média de 3,8 gramas por dia (ACN Nassif Filho, SG Bettega, S Lunedo, JE Maestri, F Gortz- Repercussões otorrinolaringológicas do abuso de cocaína e/ou crack em dependentes de drogas. Revista das Associação Médica Brasileira, 1999; 45(3): 237-41). Segundo o IC/PR, a médica de uso de cocaína, na forma de crack, é de 15 pedras diárias e de acordo com a Pesquisa Nacional sobre o Uso de Crack realizada por meio da parceria entre SENAD/MJ e a Fundação Oswaldo Cruz-FIOCRUZ é de 11 até 16 pedras diárias. A referida pesquisa destaca, no entanto, que não há como definir de forma minimamente precisa o peso em gramas e o conteúdo do que cada usuário denomina 'pedra'. Desse modo, há uma subjetividade intrínseca às definições utilizadas pelos próprios usuários. Inobstante a ressalva feita pela pesquisa, a informação técnica nº 023/2-13 SETEC/SR/DPF/RS (Superintendência Regional da Polícia Federal do Estado do RGS), constata que cada pedra de crack pode variar de 01 a 1,5 gramas. Segundo o estudo realizado na Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, a quantidade consumida por usuários de crack variava entre 1 a 15 gramas diárias, sendo que a média identificada foi de uso de 5,2 gramas por dia'. Ainda, no trabalho "Usuário de drogas ilícitas internados em hospitais psiquiátricos: padrões de uso e aspectos demográficos e epidemiológicos", de Paulo Borini e outros, publicado pelo Jornal Brasileiro de Psiquiatria, órgão oficial do IPUB Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do RJ, volume 52, mai/jun 2003, estudo realizado em um hospital psiquiátrico, informa que cerca de 51% são usuários de monodroga e 49% de polidroga. Indica que o consumo diário era igual ou menor de 15 (quinze) gramas de crack, 10 (dez) gramas de maconha e 5 (cinco) gramas de cocaína." (p. 8-9 do Acórdão)".

Outrossim, é necessário atentar-se ao fato de que a discricionariedade policial, consistente no poder de apontar se o indivíduo abordado é usuário ou traficante, deve ser contida em âmbito judicial. Como explica, a propósito, Luís Carlos Valois: "A possibilidade de aquele policial militar decidir, na esquina, se a pessoa abordada é usuária ou traficante de drogas é a mais grave das discricionariedades dessa guerra [guerra às drogas]. Do veredito das ruas poucos podem se livrar e, sacramentado o julgamento, seguirá o indiciado tendo que provar sua inocência com a grande dificuldade de um processo onde todas as testemunhas são policiais" (VALOIS, Luís Carlos. O direito penal da guerra às drogas. 3. ed. Belo Horizonte: D'Plácido, 2019, p. 28).

Por isso, para conter eventuais abusos e evitar injustas condenações, é necessário demonstrar, de maneira inequívoca, que as drogas apreendidas em poder dos acusados se destinavam à comercialização, o que não ocorreu no presente caso. Assim, impõe-se a desclassificação, conforme já decidiu o Tribunal de Justiça:

"PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. Apelo do Ministério Público pela condenação por tráfico, nos termos da denúncia. Inadmissibilidade. Não demonstrado o intuito de entrega do entorpecente a consumo de terceiros. Aplicação do princípio in dubio pro reo. Desclassificação mantida. Apelo ministerial desprovido. Julgada extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, prejudicado o apelo defensivo" (TJ-SP, 1ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal n. 0001018-89.2017.8.26.0542, Rel. Diniz Fernando, julgado em 16/3/2020).

Com isso, resta configurada a conduta de uso de drogas, e mostra-se imperiosa a desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas e exsurtem algumas consequências.

a) Da absolvição por inconstitucionalidade do tipo

A primeira delas é a necessária absolvição em razão da inconstitucionalidade do referido tipo previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, o qual fere o disposto no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal. Isso porque é inquestionável que a criminalização da posse de drogas para consumo pessoal afeta de modo desproporcional o direito ao livre desenvolvimento da personalidade e à

autodeterminação, em suas diversas manifestações.

Nas palavras de Salo de Carvalho: "Os direitos à intimidade e à vida privada instrumentalizam em nossa Constituição o postulado da secularização que garante a radical separação entre direito e moral. Neste aspecto, nenhuma norma penal criminalizadora será legítima se intervier nas opções pessoais ou se impuser padrões de comportamento que reforcem concepções morais. A secularização do direito e do processo penal, fruto da recepção constitucional dos valores do pluralismo, da tolerância e do respeito à diversidade, blinda o indivíduo de intervenções indevidas na esfera da interioridade. Assim, está garantida ao sujeito a possibilidade de plena resolução sobre os seus atos (autonomia) [...]" (CARVALHO, Salo de. A política criminal de drogas no Brasil: estudo criminológico e dogmático da Lei 11.343/06. 8. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 343-344).

Adicionalmente, o art. 28 da Lei de Drogas ofende o princípio da lesividade. Ora, um dos preceitos básicos do Direito Penal é a alteridade da lesão, vale dizer, somente se pode criminalizar conduta que ofenda bem jurídico alheio. Como escreve, a propósito, Nilo Batista: "O mesmo fundamento veda a punibilidade da autolesão, ou seja, a conduta externa que, embora vulnerando formalmente um bem jurídico, não ultrapassa o âmbito do próprio autor, como por exemplo o suicídio, a automutilação e o uso de drogas. No Brasil, o art. 28 da Lei n. 11.343, de 23.ago.2006, que incrimina o uso de drogas, em franca oposição ao princípio da lesividade e às mais atuais recomendações político-criminais" (BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. 12. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 90).

Se é assim, tem-se que o consumo de drogas não ofende qualquer bem jurídico alheio, centrando-se na livre determinação do indivíduo que opta por fazer uso do entorpecente.

Desse modo, é inquestionável que qualquer lesão potencial e suposta à saúde pública não pode ser utilizada para legitimar a intervenção penal no indivíduo. A título exemplificativo, o tabaco e o álcool ofereceriam lesividade, mas sua venda e consumo não são criminalizados. Para tais casos, é incontestável que o incremento de medidas restritivas de caráter administrativo, assim como políticas públicas de conscientização sobre o uso abusivo de tais substâncias se mostram eficazes. O mesmo raciocínio deve ser aplicado em relação às demais drogas.

Anote-se, em reforço, que a criminalização do usuário tem o efeito perverso de rotulá-lo como marginalizado, o que dificulta a sua recuperação, especialmente em se tratando de jovens, que são o principal grupo consumidor de substâncias ilícitas.

Diante da alegação ora invocada, de rigor seja declarada a inconstitucionalidade do tipo penal, em sede de controle difuso, com consequente afastamento da imputação da conduta tipificada pelo art. 28 da Lei de Drogas e absolvição, na forma do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

b) Da aplicação de sanção na forma do art. 28 da Lei de Drogas

Rejeitada a pretensão de inconstitucionalidade, mas operada a desclassificação, é o caso de aplicação das sanções cominadas pelo art. 28 da Lei de Drogas.

- DAS ALEGAÇÕES RELATIVAS À DOSIMETRIA DA PENA

a) Da pena-base

Na remota hipótese de condenação, de rigor a fixação da pena-base em seu mínimo legal: as consequências e a culpabilidade são normais para o caso, não justificando uma reprovação penal maior.

No mais, as condenações anteriores devem ser avaliadas na segunda fase de fixação de pena, sob pena de bis in idem.

b) Da segunda fase da dosimetria

Na segunda fase, a circunstância atenuante da confissão deve ser reconhecida ainda que seja apenas a informal.

c) Da incidência da causa de diminuição prevista pelo art. 41 da Lei de Drogas

Caso se tome como verdadeira a versão policial, tem-se que Douglas acabou por indicar o local onde se encontrava a maior parte da droga, permitindo a sua apreensão.

Dispõe o artigo 41 da Lei de Drogas que "o indiciado ou acusado que colaborar

voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um terço a dois terços”.

Não obstante a Lei nº 11.343/2006 não defina o que é “produto do crime”, ela o diferencia da ideia de “proveito” previsto no art. 60 desse diploma normativo, que seria o benefício econômico advindo o tráfico, por exemplo, o dinheiro.

Guilherme de Souza Nucci estabelece, especificamente no contexto do art. 41 da Lei de Drogas, que “produto do crime” é a droga e não o lucro ou vantagem que a sua inserção no mercado acarretaria: “Menciona a norma do art. 41 o produto do delito e não o proveito. Logo, é a substância entorpecente, que necessita ser recuperada, total ou parcialmente [...]” (NUCCI, 2017, p. 979).

Assim, uma vez compreendido que o produto do crime é a substância entorpecente propriamente dita, uma vez que o acusado tenha voluntariamente colaborado para sua localização, terá ele direito à redução da pena.

Nesse ponto, cabe esclarecer que os requisitos do art. 41 da Lei de Drogas devem ser interpretados de forma alternativa, em conformidade com o instituto da colaboração premiada previsto na Lei de Organização Criminosa, aplicando-se a minorante nos casos de efetiva contribuição para localização das drogas OU de identificação de coautores ou partícipes.

Isso porque a cumulatividade dos requisitos a um só tempo (i) feriria o princípio da proporcionalidade ao não valorar o efetivo auxílio prestado pelo acusado à autoridade policial; (ii) retiraria a efetividade da norma legal quando o tráfico não fosse praticado em concurso de pessoas; (iii) colidiria com os objetivos do legislador ao prever a colaboração como meio de produção de provas e (iv) representaria indevida confusão entre os institutos da delação premiada e da colaboração premiada, na medida em que aquele é espécie deste último, que tem incidência mesmo que não se delate qualquer comparsa.

Assim, de forma a conferir racionalidade e eficácia à norma contida no art. 41 da Lei de Drogas, mostra-se necessário adotar uma interpretação sistêmica e teleológica do instituto da colaboração premiada, analisando-o à luz da normativa prevista na Lei de Organizações Criminosas.

O artigo 4º da Lei nº 12.850/13 prevê cinco formas alternativas – segundo o caput do artigo – por meio das quais o(a) acusado(a) poderá colaborar com a investigação e com o processo: (i) identificar os demais coautores e partícipes da organização criminosa e as infrações penais por eles praticadas; (ii) revelar a estrutura hierárquica e a divisão de tarefas da organização criminosa; (iii) prevenir as infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa; (iv) recuperar total ou parcialmente o produto ou o proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa e (v) localizar o paradeiro de eventual vítima com sua integridade física.

De acordo com o regime jurídico da Lei de Organizações Criminosas, é suficiente, portanto, que apenas uma dessas situações esteja preenchida para que o(a) acusado(a) faça jus à redução da pena.

Para Claudia Lima Marques, entre a Lei de Drogas e a Lei de Organizações Criminosas há um diálogo de influências recíprocas sistemáticas, existente quando os conceitos estruturais de uma lei são influenciados por outra. “É a influência do sistema especial no geral e do geral no especial, um diálogo de duplé sens (diálogo de coordenação e adaptação sistemática)” (MARQUES, 2007, p. 91).

Destarte, adotando-se uma interpretação sistêmica e teleológica do art. 41 da Lei de Drogas, em consonância com a normativa geral posteriormente trazida pela Lei de Organizações Criminosas, faz-se imprescindível admitir a alternatividade dos requisitos da colaboração premiada, aplicando-se o redutor de pena quando o auxílio do(a) acusado(a) resultar na recuperação total ou parcial da droga, independentemente da delação de outros agentes.

No presente caso, verifica-se dos depoimentos prestados pelos policiais, tanto em sede policial quanto em juízo, que a colaboração do réu foi imprescindível para a localização da maioria dos entorpecentes sendo certo que o referido auxílio foi por ele prestado de forma voluntária.

Evidente, portanto, que o réu colaborou voluntariamente com as investigações, tendo seu auxílio permitido a localização do “produto do crime”, qual seja, os entorpecentes destinados ao tráfico, fazendo jus, assim, à causa de diminuição de pena expressa no referido artigo.

De mais a mais, com relação ao quantum da minorante, é necessário que seja aplicado no patamar máximo, de 2/3 (dois terços) porque se não fosse a colaboração voluntária de Douglas, possivelmente a maior porção dos entorpecentes apreendidos não teria sido apreendida.

- DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

No que tange ao regime inicial, em atenção ao disposto no art. 33, § 3º, diante da quantidade pena a ser aplicada e das circunstanciais judiciais, inexistindo fundamentação concreta a recomendar o regime mais gravoso (Súmulas 718 e 719 do STF; Súmula 440 do STJ), de rigor a aplicação do regime diverso do fechado. Adicionalmente, para a fixação do regime inicial, não poderá ser observado o disposto no art. 1º, § 2º, da LCH, tendo em vista que a declaração de inconstitucionalidade pelo STF, exercendo sua função típica de guardião da Constituição e, por isso, proferindo uma decisão de observância obrigatória por todo o Judiciário (CF, art. 102 c. c/ art. 927 do CPC).

- DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA COMO TEMPO DE PENA JÁ CUMPRIDO (DETRAÇÃO E ART. 387, § 2º, DO CPP)

Além disso, considerando que o réu respondeu preso ao processo, impõe-se que o tempo de prisão provisória seja declarado como tempo de pena já cumprida, efetuando-se, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, a detração; é o que se extrai do referido dispositivo, assim como da Exposição de Motivos da Lei n. 12.736/2012 e da jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 652.915/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016).

- DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE

Finalmente, deve ser assegurado ao acusado o direito de apelar em liberdade. De acordo com o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, ao proferir uma sentença de condenação, “O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”. Ademais, a decisão pela manutenção da prisão preventiva deve ser concreta, cabendo ao julgador “[...] indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada” (CPP, art. 315, § 2º). Com efeito, uma vez encerrada a instrução, ainda que se entenda pela manutenção da prisão preventiva anteriormente exposta, a decisão deve ser concretamente fundamentada, visto que ainda vigente o estado de inocência (CF, art. 5º, LVII; CADH, art. 8.2).

No mais, no atual cenário, qualquer decisão que determina o recolhimento de alguém ao cárcere ou a manutenção de uma prisão anteriormente decretada deve ser ponderada à luz da crise sanitária causada pelo COVID-19. Considerando a situação emergencial de saúde pública decorrente do coronavírus (COVID-19), somada ao fato de que estabelecimentos em que há aglomeração de pessoas privadas de liberdade são muito mais suscetíveis à disseminação de doenças virais, e visando a reduzir ao máximo os riscos advindos de uma possível contaminação por coronavírus, principalmente dos sujeitos ainda protegidos pela presunção de inocência e acusados de crime não considerados graves, mostra-se imperiosa a concessão do direito de apelar em liberdade, caso o acusado seja condenado.

Em seguida pelo(a) MM.Juiz(a) foi dito o seguinte:

Passo a proferir a seguinte sentença:

VISTOS.

DOUGLAS MARCEL PEREIRA CARDOSO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 13 de dezembro de 2021, por volta de 16h40, na Rua João Candido Rosa, nº 98, Novo Horizonte, nesta cidade e Comarca de Piracicaba/SP, trazia consigo, para entregar ou fornecer ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 07 (sete) eppendorfs contendo cocaína, com peso líquido de 1,2g (um grama e dois decigramas) (item 3) e 10 (dez) porções de crack, substância derivada da cocaína, com peso líquido de 1,1g (um grama e um decigrama) (item 04), e guardava, para entregar ou fornecer ao consumo

de terceiros, ainda que gratuitamente, 42 (quarenta e duas) porções de crack, substância derivada da cocaína, com peso líquido de 5g (cinco gramas) (item 01) e 51 (cinquenta e um) eppendorfs contendo cocaína, com peso líquido de 12,7g (doze gramas e sete decigramas) (item 2), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, o réu estava comercializando porções de cocaína e crack no endereço acima descrito. Estratégia comum na traficância, trazia poucas porções consigo e escondia maiores quantidades em local próximo a seu "ponto de venda".

Ocorre que, ao sair de um terreno baldio, Douglas se deparou com policiais militares e - em comportamento notadamente furtivo - adentrou numa padaria.

Abordado e revistado, foi localizada em sua posse uma pochete contendo 07 (sete) eppendorfs de cocaína, 10 (dez) porções de crack e R\$30,00 (trinta reais) em espécie.

Informalmente, o réu confirmou a prática delitiva e indicou o local, no interior do terreno baldio, onde escondia outras 51 (cinquenta e um) eppendorfs de cocaína e 42 (quarenta e duas) porções de crack.

Na Delegacia, Douglas afirmou que escondia apenas 10 (dez) porções de cocaína no terreno, as quais seriam comercializadas. Negou a propriedade das demais drogas (fls. 04/05).

Em exame pericial, foi constatada a presença de cocaína nas substâncias apreendidas (auto de exibição fls. 10/11, foto fls. 12 e laudos periciais fls. 15/18 e 74/75).

Diante das circunstâncias, notadamente a visualização de movimentação típica de mercancia ilícita, a condição pessoal do agente, a apreensão de porções de crack e cocaína em quantidade e forma incompatíveis com a mera destinação pessoal, acompanhadas de dinheiro em espécie, é certo que o réu trazia consigo e guardava os entorpecentes com a finalidade de comércio ilícito.

A denúncia foi oferecida (fls. 85) sendo determinada a notificação do réu para oferecer defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/06 (fls. 89/90).

O réu foi notificado (fls. 95) e apresentou defesa prévia, na qual requereu a revogação da prisão preventiva e alegou inocência (fls. 99/102).

A denúncia foi recebida, designando-se audiência (fls. 112/115). O réu foi citado (fls. 132).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns, sendo o réu interrogado.

Encerrada a instrução, em memoriais, as partes se manifestaram.

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

1) Da materialidade

A materialidade criminosa está consubstanciada no auto de exibição e apreensão de fls. 10/11, na fotografia de fls. 12, no laudo de constatação de fls. 16/18 e no exame químico-toxicológico de fls. 77/79, segundo o qual foi detectada a presença de cocaína, nas substâncias apreendidas.

2) Da autoria

A autoria ficou demonstrada nos autos.

Na fase investigativa, o réu disse que acabara de esconder dez porções de cocaína num terreno baldio, quando foi surpreendido pela Polícia Militar. Venderia as porções para ganhar dinheiro. Não disse de onde vieram as substâncias. A totalidade da droga não lhe pertencia (fls. 04).

Em Juízo, o réu afirmou que estava dentro da padaria comprando, quando o policial o abordou e o retirou do estabelecimento. Ele perguntou se tinha drogas e respondeu que não. Os policiais encontraram R\$ 180,00 dentro de sua bolsa e 02 parangas de maconha. Falou aos policiais que havia 10 porções de cocaína no terreno, que eram suas, mas eram para seu consumo próprio. Não sabe da existência do restante da droga. Ele mesmo indicou aos policiais onde estavam as 10 porções, ou seja, debaixo da porta. Guardou a droga, para não entrar na padaria com ela. Esqueceu de tirar a maconha da bolsa e, por isso, entrou na padaria com ela. Tinha acabado de comprar a droga no mesmo bairro, onde é ponto de droga. Faz uso de maconha e, às vezes, cocaína. Conseguia ficar sem consumir a droga. Tem contra os policiais o fato de

que tinha menos drogas.

A autoria restou comprovada nos autos, conforme se verifica das provas. Vejamos. O policial militar Douglas Walter Radeschi de Toledo asseverou que estavam em patrulhamento, quando ingressaram na rua e viram o réu saindo de um terreno, que é comumente usado por traficantes, para guardar drogas. Quando avistou a viatura, ele entrou numa padaria. Desembarcaram da viatura e o abordaram. O réu estava na posse de uma pequena bolsa, na qual havia cocaína, crack e R\$ 30,00. Indagado, o réu afirmou que a droga era para consumo, mas depois, acabou admitindo o tráfico de drogas, indicando que o restante do entorpecente estava no terreno, debaixo de uma porta. Nesse terreno, debaixo da porta, encontraram 51 pinos de cocaína e 42 pedras de crack. Todas as drogas estavam embaladas da mesma forma. O local é conhecido ponto de venda de drogas.

O também policial militar Edivaldo da Silva Santos relatou que estavam em patrulhamento, quando ingressaram no endereço da denúncia, já conhecido como ponto de venda de drogas. Nessa rua, existe um terreno baldio, onde os traficantes costumam esconder drogas. Quando se aproximaram desse terreno, viram o réu saindo do terreno. Assim que o réu percebeu a aproximação da viatura, atravessou a rua e entrou numa padaria, onde foi abordado. O réu trazia consigo uma pochete a tiracolo, onde encontraram 07 porções de cocaína e 10 porções de crack, além de R\$ 30,00. O réu acabou confessando que estava vendendo drogas. O restante da droga foi encontrado no terreno baldio, debaixo de uma porta quebrada, dentro de uma sacolinha, onde havia 51 porções de cocaína e 42 pedras de crack. Deram voz de prisão ao réu. Foi o réu que falou que a droga estava no terreno baldio, debaixo da porta. As embalagens eram todas semelhantes.

A primeira questão a ser analisada nos autos é o envolvimento do réu com a droga apreendida.

O réu, em solo policial, confirmou que as drogas que estavam em sua posse, na pochete, eram destinadas à venda, mas negou a propriedade do restante da droga apreendida. Em Juízo, o réu alegou que só tinha 02 parangas de maconha em seu poder e guardava 10 porções de crack debaixo da porta, no terreno baldio.

Os policiais militares narraram que avistaram o réu saindo de um terreno baldio, conhecido por ocultar entorpecentes. Assim que avistou a viatura, o réu tentou disfarçar e ingressou numa padaria, do outro lado da rua, onde foi abordado. Em sua posse, os policiais encontraram uma pochete, dentro da qual havia 07 porções de cocaína, 10 porções de crack e R\$ 30,00. Questionado, o réu confessou que estava na prática do tráfico de drogas e que havia mais entorpecente escondido no terreno, embaixo de uma porta quebrada. No local indicado pelo réu, os policiais encontraram mais 51 porções de cocaína e 42 porções de crack.

Com efeito, existem duas versões sobre o mesmo fato: a do réu, que alega tinha apenas 02 parangas de maconha e guardava 10 porções de cocaína no terreno; e a dos policiais militares, que indicam que o réu estava na posse de parte da droga e confirmou que escondia o restante no terreno, exatamente no local onde mais droga foi encontrada.

Resta saber se o réu tinha ou não envolvimento com toda a droga apreendida.

O réu foi visto deixando o terreno baldio, sem qualquer explicação razoável para isso.

Ademais, a droga apreendida tinha as mesmas características de embalagem daquelas apreendidas em poder do réu (porções de crack em plástico retorcido e porções de cocaína em microtubos rosa), consoante fotografia de fls. 12.

Por outro lado, os policiais relataram que encontraram o restante da droga exatamente no local indicado pelo réu, dentro do terreno baldio.

Por fim, a palavra dos policiais militares, como funcionários públicos que são, tem validade como prova, a menos que haja alguma prova de que têm interesse no resultado da demanda penal. Ressalto que o depoimento das autoridades foi firme, unânime e inquestionável.

Nesse sentido, já se manifestou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

"[...] no que atine à questão da validade dos depoimentos funcionais, esta eg.

Corte também é pacífica no sentido de que eles merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer servidor estatal no exercício de suas

funções, principalmente, quando ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados". (HC 705.060/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDF), QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

(...) 3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso". Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). (...) (AgRg no AREsp 1934729/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022)

(...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...) (AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019). Ressalto que os policiais militares não conheciam o réu e, se quisessem prejudicá-lo, poderiam ter feito com menor quantidade de drogas.

Assim, a distinção cabível, neste momento processual, é sobre a existência do dolo que comprova a traficância.

O elemento subjetivo do tipo, como diz respeito à intenção do agente, contida em seu interior, não é perceptível logo de início, mas sim aferível por meio das circunstâncias externas que acabam por traduzir o interior do agente. Entende a jurisprudência:

"O aferidor, que marca as fronteiras entre os tipos penais previstos nos artigos 12 e 16 da Lei 6368/76, reside na finalidade com que a erva é guardada, transportada, adquirida ou tida em depósito. Se para exclusivo uso próprio o delito é o do artigo 16 e, caso contrário, se configura do artigo 12" (TJRS - Ver. 695102699 - Rel. José Eugênio Tedesco - RJTJRS 175/54).

"Para a caracterização do crime de narcotráfico, como em relação aos demais delitos punidos na Lei 6368/76, atender-se-á à quantidade da substância apreendida, ao local e condições em que se desenvolveram a ação criminosa, às circunstâncias da prisão, bem como à conduta e aos antecedentes do agente, tal como dispõe o artigo 37, da referida lei" (TJRS - Ver. - Rel. Rubens Rebelo Magalhães - RJTJRS 74/11).

No caso dos autos, o réu alegou que a droga que lhe pertencia era destinada ao comércio. A prova confirma essa destinação e consumo de terceiras pessoas. Inicialmente, o réu foi visto saindo de terreno baldio usado para a guarda de drogas.

Ao observar a aproximação da viatura, o réu demonstrou comportamento suspeito, esquivando-se para dentro de uma padaria, revelando conduta ilícita.

A quantidade e diversidade de droga apreendida (58 microtubos de cocaína e 52 porções de crack) também indicam que a droga não seria consumida pelo réu, porquanto usuários não costumam manter essa quantidade de droga consigo, na rua. O fato de o réu manter pequena quantidade de droga em seu poder e esconder o restante em terreno baldio de onde podia visualizá-la, é esquema comum utilizado pelos traficantes.

Com o réu, havia dinheiro, cuja origem lícita não foi comprovada.

Aos policiais militares, informalmente, e à autoridade policial, o réu confessou que estava na prática do tráfico de drogas.

Assim, o local da abordagem, a existência de drogas com o réu e nas proximidades, a quantidade e diversidade da droga apreendida, a existência de dinheiro, a confissão policial, tudo revela que a droga era destinada ao consumo de terceiras pessoas.

Ressalto que ainda que o réu seja usuário de entorpecente, a traficância não fica afastada, uma vez que várias pessoas nessas condições acabam por vender entorpecentes até mesmo para sustentar o seu vício ou pagar dívida de drogas. Além disso, a dependência refere-se à imputabilidade e não à caracterização do delito. Diz a jurisprudência:

"A condição de dependente químico não elide a prática do delito de tráfico de drogas." (TJAC - Processo: EI 10414920108010001 AC 0001041-49.2010.8.01.0001 - Relator(a): Pedro Ranzi - Julgamento: 27/04/2011 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno - Publicação: 30/04/2011).

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA. SUFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE ENTORPECENTE. DESCABIMENTO. Acusada que admitiu a venda de entorpecentes. Apreensão de grande quantidade de "crack", aliada às demais circunstâncias do flagrante, que impedem a conclusão de que os entorpecentes se destinassem ao consumo próprio. FIGURA DO USUÁRIO-TRAFICANTE. A condição de dependente químico está relacionada ao conceito de imputabilidade (pressuposto de aplicação da pena) e não interfere na subsunção do fato ao tipo penal. Condição de toxicômano que não elide a conclusão de que a ré se dedicava à narcotraficância. Figura do usuário-traficante amplamente admitida pelos tribunais. Defesa, ademais, que sequer se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada dependência química da acusada. Condenação pelo crime de tráfico mantida. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO." (TJSP - Processo: APL 182718720088260451 SP 0018271-87.2008.8.26.0451 - Relator(a): Amado de Faria - Julgamento: 13/09/2012 - Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal - Publicação: 20/09/2012).

"A simples alegação de o agente ser viciado em drogas não tem o condão de desclassificar a conduta, mormente se surpreendido na posse de grande quantidade de entorpecente, de molde a evidenciar finalidade de venda" (TJRN, Ap. 00.001954-2, Câ. Crim., j. 1º.06.2001, rel. Juiz João Rebouças, V.U., RT 796/688).

"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando à última, de maior gravidade" (TJSP - HC 42.229-3 - Rel. Onei Raphael